

1501119-43.2019.8.26.0005

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: JULIANA NISHINA DE AZEVEDO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... reincidência, referente ao crime de tráfico de entorpecentes - Gravidade do crime precedente que não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Regime intermediário bem fixado - Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 0009069-08.2016.8.26.0451; Relator (a): Rodrigo Pares Andreucci; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

2ª Vara Criminal

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, São Paulo-SP - cep 08040-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501119-43.2019.8.26.0005 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501119-43.2019.8.26.0005

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Contravenções Penais

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3021537/2019 - 50º D.P. ITAIM
PAULISTA, 3883295 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

Leandro Matias Francisco

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA NISHINA DE AZEVEDO

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, da Lei 9.099/95.

A materialidade do crime capitulado na denúncia veio provada pela prova pericial.

Nas fls. 35/37, do laudo pericial produzido, constatou-se que:

"Após os exames, aponta o Perito Relator que a(s) máquina(s) eletrônica(s)

encontrada(s) no interior do imóvel em referência possui(m) aparência de

"Máquina(s) Sorteadora(s) Aleatória(s) de Resultados.(...) possuíam características daquelas utilizadas para máquinas para prática de jogos de azar, entretanto, não possuíam dispositivos de memória." - grifo nosso

Na fl. 36, foi consignado que as máquinas apreendidas encontravam-se operantes e,

na conclusão do laudo (fl 37), constatou-se que os aparelhos possuíam

características daqueles utilizados para prática de jogo de azar, em que presente a álea como elemento determinante para o ganho ou perda pelos jogadores. Não há, portanto, dúvida quanto à idoneidade dos objetos para o fim contravencional.

A autoria também restou devidamente demonstrada pelo depoimento das testemunhas. O policial Samuel declarou que foi acionado para apurar denúncia anônima acerca de exploração de máquina caça níquel. No local, uma pequena loja de perfumes, encontraram duas máquinas desligadas, no fundo da loja. Estavam em local acessível ao público. Não conhecia o réu anteriormente. Ele estava na loja e disse que uma pessoa instalou as máquinas e disse que dividiriam o dinheiro obtido. Do mesmo modo, a testemunha Eduardo declarou que estava em serviço, quando foi chamado para

apurar denúncia de exploração de máquina caça níquel. No local, ao fundo da loja, estavam duas máquinas desligadas. Era local acessível ao público, separado por um biombo. O réu estava lá e disse que uma pessoa instalou as máquinas. Não conhecia o réu anteriormente. Provada, está, portanto, a autoria. A negativa do acusado, na fase extraprocessual, ficou isolada e sem credibilidade.

No mais, pontua-se que a contravenção penal prevista no artigo 50 do Decreto-Lei 3.688/1941 consiste na exploração de jogo de azar e não da propriedade da máquina. Dessa forma, a conduta descrita no tipo penal foi efetivamente praticada pelo acusado, já que permitiu a instalação de máquina destinada ao jogo de azar em seu estabelecimento.

Ressalta-se que dispensável para a configuração da contravenção que houvesse apostadores ou a demonstração de efetivas apostas, bastando, como se provou no caso vertente, que estivessem máquinas programadas para jogo de azar acessíveis ao público.

Nesse sentido a jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAÇÃO PENAL DE EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR (LCP, ART. 50, CAPUT). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS E NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU QUE TINHA EM

SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL MÁQUINA CAÇA-NÍQUEL À DISPOSIÇÃO PARA JOGO.

CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO". (Apelação Criminal nº

2009.040244-5, de Balneário Camboriú. Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco. J.

19.05.2011) grifo nosso

"APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAÇÃO PENAL. CAÇA NÍQUEL CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CONFIRMANDO QUE O LOCAL ERA DESTINADO A EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. APREENSÃO DE 21 (VINTE E UMA) MÁQUINAS DE CAÇA-NÍQUEL E ELEVADA QUANTIA EM, DINHEIRO. PROVAS DEMONSTRANDO QUE, DE FATO, AS MÁQUINAS APREENDIDAS ESTAVAM EXPOSTAS E EM PLENO FUNCIONAMENTO, FAVORECENDO O JOGO ILÍCITO. LOCAL ACESSÍVEL AO PÚBLICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NOS TERMOS DA LEI PENAL E LEVANDO-SE EM CONTA A QUANTIDADE DE MÁQUINÁRIO APREENDIDO. APENADO QUE JÁ POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS. INVIÁVEL A CONVERSÃO DO REGIME A ELE APLICADO. TERMO CIRCUNSTANCIADO LAVRADO PELA POLÍCIA MILITAR. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SUAS RAZÕES E FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO".

(STF.RE 979730, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 01/08/2016)

Saliente-se, ademais, que, de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a contravenção penal descrita na demanda é delito de mera conduta, sendo irrelevante se as máquinas estavam desligadas ou desprovidas de numerários no momento em que apreendidas. Dessa forma, inexiste escusa defensiva apta a afastar a condenação.

Nesse sentido:

"Contravenção de Jogo de Azar (máquinas caça-níqueis) -Materialidade perfeitamente demonstrada - O laudo pericial de fls. 06/141 é claro em dizer que, nas máquinas apreendidas, o ganho independe da habilidade do jogador, caracterizando, pois, jogo de azar - Autoria bem demonstrada - Recorrente que admitiu ser o proprietário do bar e que as máquinas estavam em seu interior - Policial que confirmou a apreensão das máquinas em seu estabelecimento - Fato de as máquinas estarem desligadas que não implica em "ausência de exploração do jogo" - Manobra corriqueira para tentar se eximir da responsabilidade penal - Máquinas em local de acesso ao público e que, para serem manuseadas, bastaria ser ligada na tomada de energia - Recorrente que já se viu envolvido na mesma atividade em outras oportunidades, conhecedor, pois, das consequências da manutenção das máquinas no estabelecimento comercial - Pena que merece reparo - Maus antecedentes que não podem prosperar, eis que a condenação que deu causa ao reconhecimento da majorante transitou em julgado posteriormente aos fatos aqui tratados - Pena que é arbitrada inicialmente em três meses de prisão simples mais o pagamento de dez dias-multa - Reprimenda acrescida em um sexto pela reincidência do acusado (fls. 84), resultando em três meses e quinze dias de prisão simples, mais onze dias-multa - Regime intermediário bem fixado pela reincidência, referente ao crime de tráfico de entorpecentes - Gravidade do crime precedente que

não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Regime intermediário bem fixado - Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 0009069-08.2016.8.26.0451; Relator (a): Rodrigo Pares Andreucci; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Piracicaba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 19/01/2021; Data de Registro: 19/01/2021) grifo nosso

APELAÇÃO CRIMINAL - JOGOS DE AZAR (ART. 50, DO DECRETO-LEI Nº 3.668/41. EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS - Sentença absolutória - Recurso ministerial - Pretendida condenação do acusado nos exatos termos da denúncia - Possibilidade - Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas - Confissão extrajudicial que vem amparada em outros elementos de convicção amealhados durante a instrução - Depoimento de policiais - Validade - Crime de mera conduta, sendo irrelevante que as máquinas estivessem desligadas e/ou sem dinheiro, já que tais condições não são exigidas pela lei, bastando apenas a destinação do equipamento ao jogo de azar - Sentença reformada - Condenação decretada - Pena fixada no mínimo legal, dada as circunstâncias judiciais favoráveis ao agente - Substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos - Cabimento - Preenchimento dos requisitos legais exigidos no art. 44, do Código Penal. Prescrição - Ocorrência - Reconhecimento ex officio da prescrição da pretensão punitiva estatal - Decurso do interstício temporal entre o recebimento da denúncia e o presente julgamento - Sentença absolutória que não é considerada marco interruptivo do prazo prescricional - Recurso ministerial provido e decretação ex officio da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. (TJSP; Apelação Criminal 0008108-98.2011.8.26.0271; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 15/12/2015; Data de Registro: 18/12/2015) grifo nosso

"CRIMINAL - JOGO DE AZAR - ARTIGO 50 DO DECRETO-LEI 3.688/41 - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA DEMONSTRADA PELA ADMISSÃO DO RÉU DE QUE ERA A O PROPRIETÁRIO DO BAR E QUE LÁ HAVIA A MÁQUINA CAÇA-NÍQUEL APREENDIDA - POLICIAL CIVIL QUE FEZ A DILIGÊNCIA E TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA, QUE DISSE PRESTAR SERVIÇOS ESPORÁDICOS NO BAR, CONFIRMARAM A EXISTÊNCIA DA MÁQUINA NO ESTABELECIMENTO - POLICIAL ESCLARECEU QUE A MÁQUINA FICAVA NUM DEPÓSITO E QUE O LOCAL ERA ACESSÍVEL AOS CLIENTES - FATO QUE, POR SI SÓ, FAZ PRESUMIR A EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR PELO RÉU - INVEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DO RÉU, PESSOA EXPERIENTE E QUE JÁ FOI CONDENADA DIVERSAS VEZES PELA MESMA INFRAÇÃO, DE QUE TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO DEIXOU A MÁQUINA EM SEU ESTABELECIMENTO CONTRA SUA VONTADE - EVIDENTE QUE ELA FOI ALI COLOCADA PARA EXPLORAÇÃO DOS JOGOS DE AZAR PELO ACUSADO - IRRELEVANTE QUE, NO MOMENTO DA APREENSÃO, ELA ESTAVA DESLIGADA E SEM DINHEIRO - CONFORME ESCLARECEU O POLICIAL CIVIL, A AÇÃO POLICIAL FOI MOTIVADA POR DENÚNCIA ANÔNIMA DA INFRAÇÃO NO LOCAL DOS FATOS E É MUITO COMUM, EM CASOS COMO ESSE, OS INFRATORES MANTEREM AS MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS DESLIGADAS, LIGANDO-AS SOMENTE QUANDO SÃO USADAS PELOS JOGADORES, PODENDO, INCLUSIVE, SER USADA EXTENSÃO ELÉTRICA PARA QUE SEJA LIGADA EM TOMADA EXISTENTE EM CÔMODO ANEXO - MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO LAUDO PERICIAL DE FLS. 30/33, O QUAL FOI CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE A MÁQUINA APREENDIDA APRESENTA-SE COMO SORTEADORA ALEATÓRIA DE RESULTADOS E O GANHO OU PERDA INDEPENDEM DE CAPACIDADE FÍSICA OU MENTAL DO AGENTE, O QUE BASTA PARA A COMPROVAÇÃO DE QUE HAVIA EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR NO LOCAL - TIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, EIS QUE NÃO FOI CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVO NA AÇÃO COM REPERCUSSÃO GERAL A RESPEITO DO TEMA A SER JULGADO PELO C. STF - CORRETA CONDENAÇÃO - RÉU PORTADOR DE PÉSSIMOS ANTECEDENTES (FLS. 44/48) E REINCENTE ESPECÍFICO (FLS. 46) - AUSÊNCIA DE ATENUANTES - PROBLEMAS DE SAÚDE DO RÉU NÃO CONSTITUEM ATENUANTES NEM CAUSAS DE ISENÇÃO DE PENA - PENA FIXADA EM 4 MESES E 2 DIAS DE PRISÃO SIMPLES E 13 DIAS-MULTA - PÉSSIMOS ANTECEDENTES E REINCENTE ESPECÍFICA IMPÕEM A FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL E IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - AUSÊNCIA DE "BIS IN IDEM" - RÉU NÃO ESTÁ PRESO POR ESTE PROCESSO, NÃO HAVENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER RECONHECIDO - QUESTÃO REFERENTE À VAGA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM REGIME FIXADO E EVENTUAL DIREITO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR EM RAZÃO DE PROBLEMA DE SAÚDE SÃO MATÉRIAS QUE CABEM AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS

FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO. ANA CLAUDIA MADEIRA DE OLIVEIRA JUÍZA RELATORA" (TJSP; Apelação Criminal 1514297-16.2018.8.26.0451; Relator (a): Ana Claudia Madeira de Oliveira; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Piracicaba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020) (grifo nosso)

Passa-se, então, à dosimetria da pena.

O acusado é primário e não possui mácula a seus antecedentes (fls. 78/79).

Nesse sentido, pontue-se que, nos termos da Súmula 444 do C. STJ:

"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base".

Por essa razão, inquéritos policiais em curso em desfavor do acusado (fls. 78/79) não serão considerados para cálculo da pena-base, tampouco se prestarão a agravar a pena.

Observando a primariedade, os bons antecedentes, e que a conduta sob julgamento não excedeu a inerente gravidade abstrata antevista pelo legislador para cominar as penas, não se observa circunstância que possa sobrelevar a sanção do mínimo. Parte-se, portanto, nessa primeira fase da dosimetria, de 03 (três) meses de prisão simples e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Finalmente, na terceira etapa do procedimento de individualização da pena, inexistentes causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a sanção de pena de 03 (três) meses de prisão simples, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nos termos do art. 33, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade. Não há necessidade de imposição de regime mais gravoso. O réu é primário e não praticou o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, nada havendo que justifique uma segregação mais severa.

Quanto à pena pecuniária, não tendo sido demonstrada condição financeira do réu que autorizasse a majoração, cada dia-multa permanecerá em seu valor mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Não estão presentes os requisitos autorizadores para a substituição prevista no artigo 44, III, Código Penal, pois o réu descumpriu, anteriormente e nestes autos, penas restritivas de direitos (fls. 65 e seguintes) de forma que as circunstâncias indicam que a substituição não é suficiente. O mesmo se diga quanto à suspensão condicional da pena.

Por fim, decido.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório inicial para CONDENAR o réu Leandro Matias Francisco, inscrito no CPF sob o n. 350.862.188-02, portador do RG n. 27666251, filho de Luiz Francisco Netto e de Francisca Matias Francisco, nascido em 22 de julho de 1959, natural de São Paulo/SP, à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de prisão simples, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 50, caput, do Decreto-lei 3.688/41.

Considerando o caráter da pena imposta, não há justificativa para a custódia cautelar. Reconheço o direito do réu de apelar em liberdade.

Determino, ademais, a destruição das máquinas apreendidas, caso tal medida ainda não tenha sido tomada. Oficie-se.

Sem custas na espécie, observando-se, ademais, que o réu é beneficiário da assistência judiciária gratuita, na medida em que assistido pela DPE e não demonstra gozar de posses incompatíveis com a pobreza.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor do patrono dativo, de acordo com o número de atos praticados, arquivando-se o presente feito, com as anotações de praxe.

P.I.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA